

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

刑法学

(上册·总论)
(第二版)

《刑法学》编写组

第九章 正当行为

 高等教育出版社

目 录

1

第一节
正当行为概述

2

第二节
正当防卫

3

第三节
紧急避险

4

第四节
其他正当行为

第九章 正当行为

/09

第一节

正当行为概述

一、正当行为的概念与特征

正当行为，是指客观上造成一定的损害结果，**形式上**符合刑法对某种犯罪规定的客观构成要件（**缺少犯罪的其他要件，从而不完全符合犯罪构成**），但**实质上**既不具有社会危害性，也不具有刑事违法性的行为（**实质违法性的排除，造成行为不构成犯罪**）。

二、正当行为的种类

明文规定：正当防卫、紧急避险（**法益衡量的原理**）

其他：自救行为、正当业务行为、法令行为、基于权利人承诺或自愿的损害行为等（**法益阙如的原理**）

三、研究正当行为的意义

实践适用层面：有助于区分正当行为与相关犯罪行为，建立法律权威性

理论研究层面：有助于更好理解刑法价值取向与犯罪的本质属性，把握罪与非罪界限

社会效果层面：有助于鼓励公民行使权利，积极与违法犯罪行为作斗争

第九章 正当行为

/09

第二节

正当防卫

一、正当防卫的概念与特征

正当防卫，是指为了使国家、公共利益、本人或他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而对不法侵害者实施的制止其不法侵害且未明显超过必要限度造成重大损害的行为。

正当防卫具有以下特征：

第一，正当防卫一般是通过对于不法侵害人的反击行为来实施的，从而具有杀人、伤害等行为表现（正当防卫有特定条件的限制）。

第二，正当防卫是针对不法侵害行为实施的正当、合法行为（正当防卫是一种合法行为）。

第三，正当防卫的目的是使国家、公共利益或者公民的个人权益免受正在进行的不法侵害（正当防卫是公民享有的一项积极权利）。

二、正当防卫的条件

（一） 目的条件

防卫必须是为了保护合法权益（防卫人已经认识到不法侵害正在发生，希望以防卫手段制止不法侵害，保护合法权益，即防卫意图，包括防卫认识和防卫目的）。

不具备防卫意图的情形：

1.防卫挑拨

防卫挑拨又称挑拨防卫，是指行为人出于侵害他人的目的，以故意事先刺激、引诱、挑衅等方法促使对方先行向自己进行不法侵害，然后借口正当防卫加害对方的行为。

二、正当防卫的条件

（一）目的条件

2.互殴行为。

所谓互殴行为，是指双方都出于侵害对方的非法意图而发生的互相侵害的行为。

3.偶然防卫。

所谓偶然防卫，是指行为人故意对他人实施侵害行为时，偶遇他人正在进行的不法侵害，其行为客观上制止了他人正在进行的不法侵害行为的情况。

上述行为从形式上看似乎符合正当防卫的客观要件，但由于行为人主观上不具备正当的防卫目的，因此不能认定为正当防卫。

二、正当防卫的条件

（二）起因条件

发生和存在不法侵害行为（即防卫起因）。

- 1.不法侵害既包括违法行为，也包括犯罪行为（必须是客观上会给社会带来某种物质性后果的行为，对伪证、诬告陷害等犯罪不能实行正当防卫）。
- 2.不法侵害必须具有违法性（a.必须是自然人的行为，不能对单位进行正当防卫；b.通常是积极的作为，具有攻击性、紧迫性和持续性；c.必须达到一定的强度，已威胁到或侵害了法益；d.主观上一般具有故意，但也可出于过失）。

二、正当防卫的条件

（二）起因条件

3.不法侵害必须客观实际存在。

“假想防卫”，是指由于防卫人主观认识上的错误，对实际上并不存在的“正在进行的不法侵害”的他人，误认为是不法侵害人而实施的反击行为，

处理：应当依据事实认识错误的处理原则来解决其法律责任问题（应认定为过失犯罪或意外事件）。

二、正当防卫的条件

（三）时间条件

不法侵害必须正在进行（即防卫时间）。

第一，不法侵害已经开始。

“不法侵害已经开始”是指侵害人已经着手并正在直接实行侵害行为（一般是指行为人已着手直接实行侵害行为，法益已经受到紧迫威胁；但某些危害严重的犯罪行为即使尚未着手实行，法益已直接面临被侵害的危险时，也允许进行防卫）。

由于不法侵害的手段、强度、侵害法益的性质以及不法侵害人的主观罪过不同，可分为以下几种情况：

(1) 对于某些故意实施的、带有明显攻击性的严重犯罪（如放火、爆炸、杀人、伤害、强奸等犯罪），只要行为人进入犯罪现场，并准备着手实施犯罪的，就可进行防卫。（现场说或面临说）

(2) 对于一般的故意犯罪（如盗窃、抢夺、敲诈勒索等犯罪），只有行为人着手实施犯罪时，才能进行防卫。（着手说）

(3) 对于过失犯罪（如过失决水罪、过失损坏易燃易爆设备罪、铁路运营安全事故罪等），只有当其以作为形式出现，且已严重威胁到法益时，才能进行防卫。（着手说）

(4) 对于其他的非犯罪的故意不法侵害（如民事违法行为、治安违法行为、劳动维权行为等），只有当其强度较大、性质较重、对法益的现实威胁十分紧迫、重大，且行为人已着手实施时，才可进行防卫。（着手说）

二、正当防卫的条件

（三）时间条件

第二，不法侵害尚未结束。

“不法侵害尚未结束”是指不法侵害行为或其导致的危险状态尚在继续中，防卫人可以用防卫手段予以制止或排除。

“不法侵害已经结束”是指行为人将侵害行为实施完毕，危害结果已经发生。即使采取防卫行为，也不能阻止法益侵害结果的发生或挽回损失；即使不采取防卫行为，法益侵害结果也不会再发生或继续扩大（a.侵害行为实施完毕，危害结果已经发生；b.行为人自动中止侵害行为，使不法侵害中途归于消灭；c.行为人被制服，失去了继续侵害的能力；d.由于其他客观原因的存在，侵害行为未能进行到底）。

第三，不符合防卫时间的情形。

(1) 防卫不适时

处理：如果防卫人对于事实存在认识错误，主观上基于防卫的意图，则排除其犯罪故意的成立。对于已经造成的实际损害结果，应当按照处理认识错误的原则处理。

(2) 预先防范措施

防卫人为了避免未来可能发生的侵害而预先采取防范措施，如为预防被盗而在墙上插上玻璃片、在菜园外拉上电网等，只有当预防措施针对正在进行的不法侵害产生实际效果且没有超过必要限度时，才成立正当防卫。如果不是对侵害人产生作用，而是造成无辜人员伤亡或重大财产损失的，则应追究其刑事责任。

二、正当防卫的条件

（四）对象条件

防卫针对的必须是不法侵害人（即防卫对象）。

所谓不法侵害人，是指不法侵害行为的实施者及其共犯，而不包括与不法侵害无关的不法侵害人的亲友等其他人员。

1.对于未达到刑事责任年龄的未成年人和不具有刑事责任能力的精神病人的侵袭行为，能否实施正当防卫？（P204）

2.对于动物的侵袭，能否实施正当防卫？（P203—204）

（五）限度条件

防卫行为不能明显超过必要限度而对不法侵害人造成重大损害（即防卫限度）。

1.理论争议

必需说	基本相适应说	相当说
只要防卫措施是制止不法侵害所必需的，即使防卫行为在强度、后果等方面超过不法侵害可能造成的损害，也是正当防卫。	只有当防卫行为和不法侵害行为在方式、强度、后果等方面基本相适应时，才成立正当防卫。	防卫行为不仅以制止不法侵害为必需，而且与其在方式、强度和后果等方面不存在过于悬殊（一体两面）。
尽管注意到了防卫目的的正当性，却忽视了防卫行为的相当性。	虽然强调了防卫行为的相当性，但忽视了防卫目的的正当性。	既重视防卫目的的正当性，又指明防卫行为的相当性。

2.适用标准

防卫是否“明显超过必要限度”，应当综合不法侵害的性质、手段、强度、危害程度和防卫的时机、手段、强度、损害后果等情节，考虑双方力量对比，立足防卫人防卫时所处情境，结合社会公众的一般认知作出判断。

防卫是否“造成重大损害”，是指是否造成造成不法侵害人重伤、死亡。

(1) 不能过分要求手段相适应，而应全面分析不法侵害的危险程度、侵害人的主观内容、双方手段、人员多少、所处环境等。

(2) 不能只比较不法侵害人已经造成的侵害与防卫人造成的损害，还要比较不法侵害人可能造成的侵害与防卫人造成的损害。

(3) 正确认识《刑法》第20条第1款和第3款之间的关系，对于不符合特殊防卫起因条件的防卫行为，致不法侵害人伤亡的，如果没有明显超过必要限度，也应当认定为正当防卫。

三、正当防卫中的特殊防卫

对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

(无限度条件，除需要具备一般正当防卫的前四个基本条件以外，特殊防卫中的不法侵害还必须具有明显的法定暴力性)

1.准确理解和把握“行凶”

- (1) 使用致命性凶器，严重危及他人人身安全的
- (2) 未使用凶器或者未使用致命性凶器，但是根据不法侵害的人数、打击部位和力度等情况，确已严重危及他人人身安全的

2.准确理解和把握“杀人、抢劫、强奸、绑架”

(1) 是指具体犯罪行为，而不是具体罪名

(2) 在实施不法侵害过程中存在杀人、抢劫、强奸、绑架等严重危及人身安全的暴力犯罪行为的，可以实行特殊防卫。

3.准确理解和把握“其他严重危及人身安全的暴力犯罪”

(1) 与杀人、抢劫、强奸、绑架行为相当，并具有致人重伤或者死亡的紧迫危险和现实可能的暴力犯罪（如劫持航空器罪、强制猥亵罪、非法拘禁罪、强迫劳动罪、暴力干涉婚姻自由罪等）

(2) 具有严重性、人身侵犯性、暴力性

四、防卫过当及其刑事责任

（一）防卫过当的概念

防卫过当是指防卫明显超过必要限度造成重大损害，应当负刑事责任的行为。

（防卫过当仅仅不满足正当防卫的限度条件，从而使其由正当变为过当，合法变为非法，无罪变为有罪。简言之，它是具有防卫性质的失当行为。）

（二）防卫过当的罪过形式

防卫过当的罪过形式只能是间接故意或过失，而不能是直接故意。

（因为防卫目的和犯罪目的相互矛盾，不可并存；间接故意或过失都没有犯罪目的，主观上没有积极追求危害结果的发生，与防卫目的不存在冲突。）

（三）防卫过当的刑事责任

1.防卫过当的定罪

根据防卫过当触犯的刑罚法规，适用具体罪名

2.防卫过当的量刑

通过综合考虑防卫手段、结果性质、过当程度、防卫目的、防卫人面对不法侵害的恐慌、紧张等心理以及不法侵害的强度、可能造成的结果、不法侵害人的过错程度等，减轻或者免除处罚

第九章 正当行为

/09

第三节

紧急避险

一、紧急避险的概念与特征

紧急避险是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的损害另一较小合法权益的行为。

第一，紧急避险是通过对合法的人身、财产权益的损害行为实施的，从而具有伤害人身、损毁财产的行为表现（紧急避险有特定条件的限制）。

第二，紧急避险是在合法权益遭受重大危险时采取的一种避免危险的紧急措施，整体上而言，保护了更大的合法权益，应受到鼓励和支持（紧急避险是一种合法行为）。

第三，紧急避险是避险人在已无可能采取其他措施避免危险的情况下，不得已采取的权宜之计（紧急避险是公民享有的一项权利）。

二、紧急避险的成立条件

（一）起因条件

紧急避险的起因条件是合法权益遭受损害危险（即避险起因）。

所谓危险，是指客观现实中存在的足以使各种合法权益遭受严重损害的紧急情况。

危险的来源主要有四种：

- （1）人的不法侵害行为。
- （2）自然灾害。
- （3）动物的侵袭。
- （4）人的生理、疾患。

假想避险并不是紧急避险，因此对他人的合法权益造成损害的，应依据对事实认识错误的原理处理，排除其故意的成立，有过失的以过失犯罪论，无过失的则以意外事件论。

二、紧急避险的成立条件

（二）时间条件

危险正在发生，对合法权益形成了紧迫的、直接的危险（即避险时间）。

第一，危险的出现

所谓危险的出现，是指某一危险事实的发生，使法益即将受到侵害；此时若不实行紧急避险，法益必然遭受侵害。

第二，危险的结束

所谓危险的结束，是指危险事实已经过去，对法益不起作用。即使采取避险行为，也不能保全法益；即使不采取避险行为，也不会使法益再遭侵害（a.危险作用完毕，损害无法挽回；b.由于避险人的努力，危险被消灭；c.由于某种客观原因，危险未对合法权益造成侵害）。

二、紧急避险的成立条件

第三，避险不适时

(1) 事前避险

(2) 事后避险

(三) 对象条件

避险行为损害的是除避险人和不法侵害人以外的其他人的合法权益（即避险对象）。

第一，合法性。

第二，次要性。

第三，牺牲性。

二、紧急避险的成立条件

（四）目的条件

行为人主观上必须有正当的避险目的，他已经认识到危险正在发生，希望以某种手段避免较大损害。（即避险意图）。

- 1.避险认识：认识到危险正在发生的事实。
- 2.避险目的：为了避免遭受危险，保护较大合法权益。

（五）限度条件

避险行为不能超过必要限度，造成不应有的损害（即避险限度）。

这意味着，避险行为造成的损害必须小于所避免的损害，侵害的法益不能等于或大于所保护的法益。

1.相同性质法益的比较

一般而言，在人身权利中，生命权大于健康权、自由权等权利；在财产权利中，价值大的财产权益大于价值小的财产权益。

2.不同性质法益的比较

通常情况下，重大的公共利益优于个人利益，人身权利大于财产权利。

（六）限制条件

避险行为必须在不得已的情况下才能实施（即避险限制）。

所谓“不得已”，是指除了实施损害第三者合法权益的避险行为以外，没有其他办法可以避免危险。

- 1.从客观上考察危险发生的现实紧迫性和避免可能性。
- 2.从主观上考虑避险人的生理条件和心理状况。

（七）禁止条件

关于避免本人危险的规定，不适用于职务上、业务上负有特定责任的人（即避险禁止）。

职务和业务上负有特定责任的人，即使在无法排除和避免正在发生的危险时，也不能进行紧急避险，必须依据自己特定的义务，积极地履行自己的职责。

第一，在本人的人身、财产和其他权利遭受危险侵害时，只要避险行为与所承担的特定责任不相冲突，职务上、业务上负有特定责任的人也可以实施紧急避险。

第二，在国家、公共利益、他人的人身、财产和其他权利遭受危险侵害时，职务上、业务上负有特定责任的人也可以实施紧急避险。

三、避险过当及其刑事责任

（一）避险过当的概念

避险过当是指避险行为超过必要限度造成不应有的损害，应当负刑事责任的行为。

（避险过当仅仅不满足紧急避险的限度条件，从而使其由正当变为过当，合法变为非法，无罪变为有罪。简言之，它是具有避险性质的失当行为。）

（二）避险过当的罪过形式

避险过当的罪过形式通常是疏忽大意的过失，但少数情况下，也可能是间接故意或者过于自信的过失。

（在避险过当的场合，避险人主观上只能出于间接故意或过失。因为避险目的和犯罪目的相互矛盾，不可并存；间接故意或过失都没有犯罪目的，主观上没有积极追求危害结果的发生，与避险目的不存在冲突。）

三、避险过当及其刑事责任

（三）避险过当的刑事责任

1.避险过当的定罪

依据避险人的主观罪过形式以及客观上的行为性质和具体损害结果，按照刑法分则中的相应条款定罪

2.避险过当的量刑

应当减轻或者免除处罚

四、紧急避险与正当防卫的异同

紧急避险与正当防卫都是为了保护国家、公共利益以及本人或者他人的合法权益，尽管客观上给他人的某种利益造成一定的损害，但由于产生了有益于社会利益的实际效果，因而法律明文规定在适当的情况下都不负刑事责任，排除其犯罪性。两者区别如下：

	正当防卫	紧急避险
危险的来源不同	只能是人的不法侵害行为	大自然的自发力量、动物的侵袭、人的不法侵害行为及其生理、病理原因

损害对象不同	不法侵害人本人	无辜的第三人
实施条件不同	无限制	不得已
限度标准不同	造成的损害可以等于甚至大于所避免的损害	造成的损害必须小于所避免的损害
主体范围不同	无要求	不适用于职务上、业务上负有特定责任的人
民事责任不同	防卫人不承担任何民事责任 (《民法典》第181条)	引起险情发生的人承担民事责任/ 紧急避险人可以给予适当补偿 (《民法典》第182条)

第九章 正当行为

/09

第四节

其他正当行为

一、自救行为

自救行为，又称为自助行为、自力救济，是指权利受到侵害的人，在无法按照正式的法律程序等待国家公权力救济时，以自己的力量求得权利恢复的行为。

二、正当业务行为

正当业务行为，又称为履行业务的行为，是指行为人根据自身从事的职业要求所实施的行为。

三、法令行为

法令行为，是指行为人根据有效的法律、法规或者依据上级组织、上级主管人员的命令而实施的合法行为。

四、基于权利人承诺或自愿的损害

基于权利人承诺或自愿的损害行为，又称为被害人承诺、经权利人同意的行为，是指行为人经过有权处理某种权益的权利人同意后实施的损害其本身利益的行为。



思考题

- 1.如何看待预先安装防卫装置的行为？
- 2.如何理解特殊防卫中“其他严重危及人身安全的暴力犯罪”的范围？
- 3.如何理解紧急避险中“另一较小合法权益”的含义？
- 4.如何看待安乐死中“权利人承诺”的问题？